

1502880-73.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA DE MENOR PODENTE CIAL LESIVO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502880-73.2021.8.26.0544 Fls. de

Aos 16 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

RYAN FARIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 09h30, na rua Humberto Primo Campana, Parque São Francisco, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 37 porções de maconha, 18 de crack e 14 porções de cocaína, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais abordaram o réu em local conhecido como ponto de venda de drogas e com ele encontraram 3 pedras de crack, 6 porções de maconha e R\$ 25,00, localizando o restante da droga num buraco no muro de uma escola.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 49/52), o réu foi notificado e citado (fls. 124) e a defensora apresentou resposta à acusação (fls. 107/109), sendo recebida a denúncia (fls. 125/126).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 132/133), e a Defesa, em essência, sustentou a fragilidade probatória para a condenação, pedindo a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (fls. 135/138).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 23/26) e de exame químico-toxicológico (fls. 119/122) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

O réu, quando da lavratura do flagrante, admitiu que estava vendendo drogas no local.

Em juízo reiterou que, passando dificuldades, vendia drogas a fim de pagar dívidas

e ao ser abordado entregou as porções de maconha e crack que tinha consigo e ainda indicou um buraco num muro onde escondia mais drogas.

Os guardas municipais confirmaram a abordagem do réu em local conhecido como ponto de venda de drogas e na revista encontraram porções de maconha, crack e cocaína e R\$ 25,00, admitindo ele que estava no tráfico e indicou o buraco de um muro onde guardava o restante das drogas.

Diante de tão cruel, doloroso e verdadeiro quadro, corroborada a confissão pelos demais elementos de convencimento, não resta outra solução a não ser condenar mais um desgraçado que se presta a vender drogas para enriquecer o verdadeiro traficante, que, certamente, outro imediatamente colocou no lugar porque a "lojinha" não pode parar.

Entretanto, de se afastar a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, na medida em que não foi produzida prova alguma de que tenha se valido o réu da proximidade de escola para praticar o comércio ilícito, visando a passar a droga para o maior número de pessoas, sobretudo porque nem os milicianos ou qualquer outra testemunha presenciaram o réu vendendo drogas para frequentadores da escola.

Reconhecidas, assim, a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena. Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a diminuta quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro para sustento do desgraçado vício, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, na medida em que as circunstâncias atenuantes genéricas da confissão espontânea e menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena a quem da mínima cominada ao delito.

Sendo o réu tecnicamente primário, não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante as penas fixadas e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a manutenção das penas-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DE DROGA DE MENOR PODENTECIAL LESIVO. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICABILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. In casu, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte a quo não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e o corréu, tendo consignado que "o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 pressupõe a reunião de propósitos para a exploração do comércio ilegal de drogas, não sendo a estabilidade elemento de sua qualificação, estando, portanto, em desacordo com a jurisprudência firmada por esta Corte.
4. No termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
5. Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei de Drogas, e tratando-se de pequena quantidade de droga de menor potencial lesivo (75,4g de maconha), é desproporcional e desarrazoada a exasperação da pena-base em 1/6, visto que não há outras circunstâncias desfavoráveis, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
6. Tendo a pena-base sido redimensionada ao mínimo legal (5 anos), tornou-se inviável a incidência da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
7. Nos termos do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
8. No caso, ao contrário do firmado pelo Tribunal de origem, entende-se que a quantidade do entorpecente apreendido não se mostra elevada, fazendo jus a paciente à aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, sobretudo quando considerada sua primariedade, bons antecedentes e a ausência, no caso concreto, de elementos indicativos de que integre organização criminosa ou de que se dedique à criminalidade.
9. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é manifestamente ilegal a imposição do regime prisional mais severo com base, exclusivamente, no disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES.
10. Estabelecida a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, verificada a primariedade da agente e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o cumprimento inicial em regime aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.
11. Preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença condenatória, de forma a absolver a paciente pelo delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, fixar a pena-base no mínimo legal para o delito de tráfico e aplicar o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, ficando a reprimenda final em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais pagamento de 194 dias-multa, bem para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da execução. (HC nº 355.047 - SP (2016/0112859-0); Relator Min. Ribeiro Dantas - Brasília (DF),

1º de setembro de 2016, g.n.)

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores – conforme jurisprudência acima mencionada – no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar RYAN FARIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo as penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Diante das penas alternativas impostas, não havendo mais necessidade da prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 16 de fevereiro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: